

0000044-18.2016.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000044-18.2016.8.26.0306 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000044-18.2016.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 398/2015 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO GABRIEL ALVES BARBOSA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LUIS GUILHERME SILVA, vulgo "Gordinho", como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal de crimes, e YAGO GABRIEL ALVES BARBOSA, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de dezembro de 2015, às 21h40min, na Avenida Joaquim Moreira da Silva, 2875, Posto TMJ, São José, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, LUIS GUILHERME SILVA, vulgo Gordinho, qualificado às fls. 83, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra José Ângelo da Silva

Neto e Eliezer Ferreira da Cunha, a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes ao Auto Posto TMJ, e um telefone celular da marca Samsung Duos, de cor branca, pertencente à José Ângelo da Silva Neto. Consta, ainda, que, na mesma data, após a prática do crime acima descrito, em horário incerto, em um bar situado no Bairro Vitoriano, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, YAGO GABRIEL ALVES BARBOSA, qualificado às fls. 100, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em no telefone celular da marca Samsung Duos, de cor branca, pertencente à José Ângelo da Silva Neto. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado Luis Guilherme, juntamente com um indivíduo não identificado, o qual estava munido com arma de fogo, foram até o posto de combustíveis acima descrito e anunciaram o assalto às vítimas José Angelo e Eliezer, frentistas do local, exigindo a entrega de dinheiro e celulares. Temerosos e sem esboçar reação, as vítimas atenderam à exigência, tendo José Angelo entregado seu aparelho de telefone celular, e Eliezer, a quantia de R\$400,00 em dinheiro. De posse da res, Luis Guilherme e o comparsa evadiram-se do local a pé sentido Bairro Jardim Vitoriano. É dos autos que a vítima Eliezer reconheceu Luis Guilherme, que tem a alcunha de "Gordinho" e cujo pai é dono de um bar no Jardim Vitoriano, tendo repassado tais informações à Polícia Militar. Em diligências, os milicianos lograram apreender o aparelho de telefone celular de José Angelo em poder do denunciado Yago, que o recebeu sabendo de sua origem criminoso, tanto que tentou se evadir ao avistar a aproximação da polícia, além do que não conseguiu apresentar qualquer justificativa plausível para a posse do bem. Auto de exibição e apreensão às fls. 09; auto de entrega às fls. 10 e de reconhecimento fotográfico a fls.42/43.

A denúncia foi recebida em 10/06/2019 (fls. 155/156).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 187).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 191) e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 290/291).

Foi realizada audiência de instrução, ouvidas as duas vítimas, as duas testemunhas e interrogados os acusados ao final.

Encerrada a instrução, manifestaram-se o Ministério Público e a defesa dos acusados em alegações finais orais, conforme gravado pelo sistema audiovisual.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito. A pretensão ministerial é PROCEDENTE.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de entrega (fls. 10), termos de declarações (fls. 11, 14 e 15), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 49/50) bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

As autorias delitivas também foram suficientemente comprovadas.

A vítima José Ângelo da Silva Neto narrou em juízo que trabalhava no posto nesta data. Ocorreu um assalto. Chegaram dois indivíduos. É a terceira vez que foi assaltado e faz um tempo, então, não lembro direito. Eles estavam de moto. Eles assaltaram a outra vítima e, depois, o depoente. Eles correram para o bairro Vitoriano. Levaram o seu celular. Não se recorda se foi a polícia, mas alguém ligou no celular e estava na casa da irmã de Yago. Não conseguiu reconhecer os roubadores. No posto, tinha câmeras de vigilância e viu as imagens. Não conseguiu reconhecer nenhum dos dois. Não foi a primeira vez que o posto foi assaltado. Recuperou o celular, na delegacia. Não sabe a explicação de Yago após os fatos. Não teve mudança de comportamento após os fatos. Um deles exibiu a arma. Não falaram nada, apenas apontaram a arma e o depoente entregou o celular.

Também ouvida em juízo, a vítima Eliezer Ferreira da Cunha disse que não se recorda muito bem. Estava abastecendo um carro. Chegaram duas pessoas encapuzadas e pediram o dinheiro. Eles pegaram o dinheiro do depoente e foram para outro lado. Eles correram. Reconheceu a voz do Guilherme, porque já o conhecia e conviveram. Não reconheceu a voz. Viu uma arma de fogo, mas não lembra com quem estava. Eles pegaram somente dinheiro do depoente. Não se recorda, exatamente, o valor. Ficou sabendo que pegaram um celular do colega. Reconheceu o réu Guilherme. Reconheceu o réu de óculos como sendo Guilherme. Reconheceu-o pela voz, pois ele teve um relacionamento com a irmã do depoente. Por isso, passou as informações aos policiais. Já o conhecia e estava acostumado com a voz dele. Eles estavam encapuzados. Não sabe se ele confessou os fatos. Após os fatos, Guilherme conversou com o depoente sobre outros assuntos. Ele fez esse contato por telefone, mas não chegou a comentar nada sobre o assalto. Ele questionou se tinha algo contra ele e o depoente falou que não tinha nada. Ele disse que estava indo na igreja. Não tem dúvidas. Não se recorda quem estava com arma. Eles não chegaram a apontar a arma. Pediram para passar o dinheiro. Eles chegaram a empurrar para apegar o dinheiro. Não sabe dizer se houve ameaça ou violência física contra José. Não sabe dizer o contexto em que o celular de José foi encontrado. Não recuperou o dinheiro do posto. Não sabe dizer se recuperaram o dinheiro. Só mudou de cidade para trabalhar. Mas não teve nenhum problema psicológico ou consequências em razão do roubo. O policial militar Bráulio de Matos Borges, em juízo, contou que atendeu a ocorrência. Recorda-se vagamente. Fez atendimento de roubo a posto de gasolina. Em contato com frentistas, eles falaram que os indivíduos anunciaram roubo com revólver, subtraindo dinheiro e celulares. Um dos frentistas disse que reconheceu uma das partes. Com as características repassadas, saíram em patrulhamento. Deparam-se com Yago, que demonstrou nervosismo ao ver a viatura. Ele correu para dentro da casa. Recorda-se que, em um certo momento, uma das pessoas ligou em um dos celulares roubados e estava com a irmã de Yago. Encontraram, na casa de Yago, droga, tesoura, faca e papel para embrulhar droga. Quanto ao celular, a irmã de Yago informou que o celular estava no quarto de Yago. Já conhecia os réus de outras ocorrências. Recorda-se do envolvimento deles com drogas. Não se recorda como foi a resposta de Yago sobre a ocorrência. Não teve contato com o outro réu Luís Guilherme.

De forma similar e harmônica foi o depoimento do policial militar Marcelo Vitor da Silva, não havendo contradições dignas de nota entre os depoimentos dos policiais que participaram diretamente da ocorrência.

Interrogado, o réu Yago Gabriel Alves Barbosa disse que tem 24 anos. Está preso há 05 anos. É amasiado. Tem uma filha de 04 anos. Antes da prisão, trabalhava na oficina de moto. Disse que estava em um bar e passou uma moto vermelha com dois indivíduos e deixou o celular cair. Pegou o celular e foi para casa. O celular estava com o visor trincado. Deixou o celular e foi para o estabelecimento. Os frentistas não o reconheceram. Já está 05 anos preso e está pagando pelo que fez. Não tem relação nenhum com o processo. O estabelecimento era na frente de casa, não tentou se evadir. Durante a abordagem, houve uma ligação para o número. A irmã atendeu. Os policiais pegaram o celular. Não viu as pessoas que deixaram o celular. A moto passou andando e o celular caiu. Conhece Luís Guilherme, porque ele mora no mesmo bairro. Era conhecido do réu Luís Guilherme. Não praticou assalto em outro posto na companhia de Guilherme. Está preso por um assalto com Luís Guilherme. Não entregou o celular para a polícia, porque invadiram a sua casa e já o levaram no posto. No posto, questionaram sobre o celular. O celular estava na sua casa, mas não o roubou. Não desconfiou que o celular era roubado. Sabia que tinham roubado um posto, mas falou que não era o autor. Não imaginou que o celular era roubado. Está preso e no semiaberto. Não tem culpa nesses fatos.

Interrogado, o réu Luís Guilherme Silva disse que tem 28 anos. Está preso há 01 ano. Antes, trabalhava de amador de ferragem e, de noite, de eletricitista. É amasiado. Não tem filhos menores de idade. Disse que os fatos não são verdadeiros. Conhece Eliezer, pois já foi casado com a irmã dele. Frequentavam a igreja juntos. Conversou com ele e não tinha ciência da acusação. Eliezer entrava no meio quando o depoente discutia com a namorada, mas ele pedia desculpa. Nunca teve briga grave

com o Eliezer. Conhecia Yago, pois a mãe conhece a mãe dele. Eles iam ao mercado da mãe. Só o conhecia de vista. Não tinha moto na época dos fatos. Não sabe o porquê Eliezer o aponta como o autor dos fatos, ele deve ter confundido. Atendia as pessoas no mercado da mãe e, por isso, via Yago no estabelecimento comercial. Conhecia-a mais em razão da Igreja. Ele cantava na Igreja. Não praticou assalto em outro posto, na mesma avenida, como Yago. Foi acusado, mas não praticou o fato. Não praticou os fatos.

Nesse contexto, verifico que o conjunto probatório reunido nos autos, sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar o decreto penal condenatório contra o réu Luís Guilherme, em relação à prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como contra o réu Yago, em relação à prática do crime de receptação.

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, CP)

Perante a Autoridade Policial, Luís Guilherme exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, o acusado negou a prática do delito. No entanto, a negativa encontra-se isolada nos autos, não devendo prevalecer.

Isto porque, a vítima Eliezer reconheceu, desde logo, o acusado Luis Guilherme durante a prática delitiva, visto que é seu conhecido, pois já foi namorado de sua irmã. Na delegacia, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas Luís Guilherme, conforme auto de reconhecimento fotográfico às fls. 49/50. Nesta audiência, o ofendido declarou que reconheceu a voz do réu, sem sombra de dúvidas.

Ressalto que nada há nos autos que indique que a vítima Eliezer tenha interesse em prejudicar Luís Guilherme, acusando-o falsamente. Com efeito, o acusado Luis Guilherme não soube apontar qualquer motivo para uma falsa acusação.

De maneira outra, as vítimas deram palavras firmes, tanto na fase policial quanto em juízo, de modo que sua versão dos fatos ganha maior credibilidade, principalmente quanto aos crimes patrimoniais, que são cometidos na clandestinidade, em que estão presentes apenas a vítima e o agente delitivo na maioria das vezes.

Destaco jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Materialidade e autoria certas – Reconhecimento idôneo pela vítima – Condenação mantida – Pena-base – Gravidade concreta para justificar a fixação acima do mínimo legal – Causas de aumento de pena – Emprego de arma de fogo – Apreensão – Prescindível – Suficiente as palavras da vítima – Concurso de agentes – Vínculo subjetivo demonstrado – Regime inicial fechado mantido – Art. 33, § 3º, do CP – Recurso não provido (0015518-37.2014.8.26.0229. Relator (a): Alberto Anderson Filho. Comarca: Hortolândia. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 21/03/2018. Data de publicação: 22/03/2018. Data de registro: 22/03/2018);

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da detração. Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Vítima reconheceu o acusado como autor do delito, sem sombra de dúvidas. Provas robustas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria não comporta reparos. Mantido o regime inicial semiaberto sob pena de reformatio in pejus. Detração. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (0084314-35.2014.8.26.0050. Relator (a): Andrade Sampaio. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/03/2018. Data de publicação: 19/03/2018. Data de registro: 19/03/2018).

No mesmo sentido, os policiais militares relataram que, após tomarem conhecimento da ocorrência, foram em busca de informações e encontraram o celular subtraído na posse do réu Yago. Segundo os policiais, as vítimas narraram que a subtração foi

praticada por dois réus, na posse de arma de fogo. Nesse ponto, ressalto que é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372). A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção “jûris tantum” de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos”. (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642). (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016).

Assim sendo, a autoria do crime de roubo é inconteste e recai na pessoa do acusado Luís Guilherme Silva.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, a prova se formou no sentido de reconhecer sua incidência, visto que Luís Guilherme estava em companhia de outra pessoa. Tal informação é trazida no depoimento de ambas as vítimas. O fato de ainda não estar identificado até o momento o copartícipe, não afasta a causa de aumento de pena, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal)– RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Inviabilidade. Conjunto probatório é seguro em concluir pela participação de outro indivíduo, ainda que não identificado. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente valoradas. Dolo normal ao tipo. Afasta-se a valoração negativa da moduladora conduta social, ante a ausência de elementos idôneos para aferição. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES. Viabilidade. A existência de 02 (duas) causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), por si só, não justifica o aumento da pena em mais de 1/3, consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Redução operada. ALTERAÇÃO DO REGIME – Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada. Inteligência do artigo 33, § 2º, b, e § 3º do CP. Súmula 440 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00603579720178260050 SP 0060357-97.2017.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 11/03/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020)(grifo nosso)

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a prova também se formou no sentido de reconhecer a sua incidência. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível à incidência da causa de aumento de pena, uma vez que basta que o agente delitivo utilize a arma para a prática do roubo, que é o caso dos autos. O legislador deu maior reprovabilidade à conduta do agente neste caso, pois considerou a potencialidade lesiva da arma, de sorte que a defesa não trouxe aos autos elementos que a desqualificasse.

A jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma pacífica a viabilidade de incidência da majorante, desde que amparada por outros elementos probatórios, o que ocorreu neste caso, conforme depoimento da vítima. Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL MANTIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. RECONHECIMENTO COM BASE EM PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1502478-72.2019.8.26.0540 -Voto nº 9 ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ CONSTATADA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O INCREMENTO SUPERIOR A 1/3. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS PELA AÇÃO DO AGENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Quanto à etapa derradeira da dosagem da pena, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). (...) 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício,

tão somente para reduzir a 1/3 o aumento pela incidência de três majorantes do crime de roubo, determinando ao Juízo das Execuções que promova à nova dosagem da pena. (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

De maneira semelhante, já decidiu o Tribunal Bandeirante:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Causas de aumento suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Desnecessidade da apreensão da arma para comprovação da causa de aumento. Inconstitucionalidade 'incidenter tantum' do aumento de 2/3 da pena previsto no §2-A do artigo 157 do Código Penal. Não acolhimento. Pena. Pena-base. Majoração em razão da presença da causa de aumento do concurso de pessoas. Admissibilidade. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a reincidência específica. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502478-72.2019.8.26.0540; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

O roubo foi consumado, pois houve a inversão da posse e perda de disponibilidade do bem pela vítima, ainda que por curto período. O celular foi recuperado momentos depois, porém, o dinheiro não foi recuperado. Destarte, a tese defensiva não merece prosperar. Também não há que se falar em desclassificação para o delito de furto, em razão dos fundamentos acima expostos e da evidente utilização de grave ameaça para a subtração.

Do crime de receptação (art. 180, caput, CP)

O acusado Yago Gabriel negou ter adquirido ou recebido o celular, pertencente à vítima, encontrado pelos policiais em posse de sua irmã Lorena. Em sua versão, disse que encontrou o aparelho que caíra do bolso de uma pessoa que conduzia uma motocicleta pela via. Lado outro, confirmou que tem amizade com o acusado "Gordinho" (Luis Guilherme).

No entanto, apesar da negativa do réu, infere-se do conjunto probatório que o réu recebeu o celular sabendo da origem criminosa, a configurar o tipo penal do artigo 180, caput, CP. Com efeito, diante da sutileza da prova do conhecimento que informa o conceito da receptação e da inafastável carga subjetiva com que se a recebe, é necessário um conjunto de indícios suficientes para firmar convicção de que o réu sabia da procedência do bem que recebeu.

Na receptação dolosa, onde se exige ciência de parte do agente, de que adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa cuja procedência criminosa, bastaria ao réu negar esse conhecimento para ser, sempre e sempre, absolvido. Por isso que a jurisprudência, acertadamente, entende que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a situação.

E, da soma de todas essas circunstâncias, é por demais evidente a certeza inquestionável de que o réu, conscientemente e de livre vontade, recebeu o celular com conhecimento de sua origem criminosa, caracterizando, assim, o dolo direto que tipifica o delito em questão.

Deveras, o celular foi encontrado com a irmã do acusado e o réu, ao ver a Polícia Militar, tentou se evadir, indicando conhecimento da origem espúria do objeto. E não é só. O réu não soube justificar ou explicar a posse do objeto subtraído. Pelo contrário, apresentou versão totalmente inverossímil, declarando que o celular caíra justamente na frente de sua residência e que apenas guardou o objeto em sua casa, sem qualquer conhecimento da origem espúria.

A versão do acusado está totalmente isolada nos autos. Aliás, os réus declararam que apenas se conheciam de vista, de um estabelecimento comercial e da Igreja em que frequentavam. Todavia, ambos já foram condenados, com sentença definitiva, pela prática de outro roubo, contra posto de gasolina na mesma avenida. Portanto, está

comprovado o vínculo existente entre os réus e, em consequência, o liame entre o roubo e o crime de receptação. Os elementos comprovam, claramente, que Yago sabia da origem ilícita do bem, apropriando-se do objeto. Portanto, não é caso de desclassificação para o delito de receptação culposa. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a posse de aparelho celular furtado no dia anterior. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como do dolo, diante das circunstâncias da abordagem. Condenação mantida. Penas mínimas, fixado o regime aberto e substituída a corporal, na forma do artigo 44, do CP. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0000027-69.2018.8.26.0319; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)

Também não se aplica o artigo 180, §5º, CP, o qual dispõe que: "Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155". O artigo 155, §2º estabelece que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa". No caso, a receptação não envolve bem de pequeno valor e o réu possuía vários processos em andamento à época dos fatos. Portanto, a aplicação do benefício é indevida.

Assim, não há dúvidas da prática do crime de receptação imputado pela denúncia ao acusado Yago Gabriel Alves Barbosa, sendo o caso de condenação.

Passo à aplicação das penas, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

LUIS GUILHERME SILVA

Verifico que o réu é reincidente (3002898-36.2013.8.26.0306 - fls. 226). No entanto, deixo de reconhecer a presença de maus antecedentes, em razão das duas condenações anteriores aos fatos ora apurados serem pelo crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas (fls. 225/228).

Sobre o tema, quanto à condenação pelo artigo 28 da Lei de drogas (fl. 241), nos termos da decisão proferida em sede liminar pelo Superior Tribunal de Justiça e na linha do mais recente entendimento que prevalece naquela Corte, ao qual me filio, a condenação anterior pelo crime de porte de drogas para consumo não se presta a gerar reincidência:

Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Assentado tal entendimento, a jurisprudência evoluiu para proibir inclusive a valoração de tais condenações penais anteriores como maus antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RESp 1909074/MG, Sexta Turma, Min. Laurista Vaz, j. 22/06/2021).

É o teor dos seguintes julgados da Corte Paulista:

Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do acusado – Circunstância reconhecida em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Condenação anterior pelo crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas que não gera maus antecedentes ou reincidência – Aplicação retroativa da jurisprudência, à luz dos princípios da igualdade e da retroatividade da norma mais benéfica – Pena ajustada – Pretensão à redução da fração de acréscimo que incidiu na segunda etapa da dosimetria, em razão da circunstância agravante da reincidência – Impossibilidade, ante a inexistência de ilegalidade na proporção adotada – Discricionariedade do julgador no dimensionamento da pena – Precedente do STF – Revisão criminal que não se presta à reanálise de questões amplamente debatidas na sentença e no acórdão condenatório – Revisão criminal parcialmente provida. (TJSP; Revisão Criminal 2223576-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico ilícito de entorpecentes - Insurgência quanto à dosimetria da pena – Condenação anterior pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 que não gera maus antecedentes – Precedentes – Penas inalteradas - Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500790-07.2020.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Considerando que estão presentes duas causas de aumento de pena, utilizo a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I, do CP para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria da pena (1/3 até metade, segundo a redação deste artigo, anterior à Lei 13.654, redação esta que deve ser aplicada, por ser mais benéfica ao réu). A outra circunstância (concurso de agentes) será valorada como circunstância judicial negativa do artigo 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, parágrafo único, do CP.

Assim, na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes, pelos fundamentos anteriormente expostos. As circunstâncias do crime são negativas, porque o fato foi praticado em concurso de agentes, a relevar maior periculosidade da ação e risco para a vítima. As demais circunstâncias (culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do crime) são normais e esperadas em delitos desta natureza. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (3002898-36.2013.8.26.0306 – fls. 226). Aumento a pena em 1/6, totalizando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena em relação ao uso de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa. Considerando que, com um único ato, o agente atingiu o patrimônio de duas vítimas

(R\$ 400,00 pertencente ao Auto Posto TMJ e um telefone celular pertencente a José Ângelo da Silva Neto), reconheço o concurso formal (artigo 70, CP). Para a pena privativa de liberdade, aumento a pena em 1/6, sendo que as penas de multa serão somadas (artigo 72, CP). Assim, fixo a pena definitiva em 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 32 dias-multa.

O crime de roubo é daqueles que amedrontam a sociedade e indicam a periculosidade do agente, merecendo uma repreensão enérgica, sobretudo para se evitar a reprodução de fatos desta natureza. No caso dos autos, o crime se reveste de gravidade em concreto, porque praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Além disso, o acusado é reincidente. Assim, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Ausentes informações sobre o tempo de prisão provisória por este delito, deixo de proceder na forma do artigo 387, §2º, CPP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo (artigo 49, § 1º, CP).

Não estão presentes os requisitos dos artigos 44 e 77 CP. Logo, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em face da pena fixada, da reincidência do réu, da insuficiência da medida e porque o crime foi praticado com violência contra a pessoa.

YAGO GABRIEL ALVES BARBOSA

Verifico que o réu, à época dos fatos, era tecnicamente primário e não ostentava maus antecedentes (fls. 220/224), pois possui apenas condenações posteriores à data dos fatos. Reconheço, em seu favor, a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos (artigo 65, inciso I e inciso III, alínea d, do Código Penal).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos (artigo 65, inciso I e inciso III, alínea d, do Código Penal). Ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo já fixado (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, a pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Para o cumprimento inicial da pena, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44, do CP, pois o réu não possuía condenações criminais à época dos fatos, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução.

Fica prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (artigo 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu:

LUIS GUILHERME SILVA, portador do RG: 36.282.464-2, CPF: 431.817.768-82, nascido em 07/11/1993, natural de Presidente Prudente - SP, filho de LUIS FERNANDO DA SILVA e SUELI PEREIRA DA SILVA, à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

YAGO GABRIEL ALVES BARBOSA, portador do RG: 49.646.900, CPF: 459.437.098-51, nascido em 05/11/1996, natural de Palestina - SP, filho de ANTONIO DA SILVA BARBOSA e MARISA ALVES, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade),

pelo mesmo tempo da pena privativa imposta, conforme estabelecido na fundamentação.

Condene os acusados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhes a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Os réus poderão recorrer em liberdade, ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, ausente pedido expresso e exercício do contraditório, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório” (STJ, HC nº 321279/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 03.08.2015).

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa" (in "Código de Processo Penal Comentado", RT, 2009, 9ª edição, pág. 701).

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Comunique-se a prolação desta sentença à vítima (art. 201, §1º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva de recolhimento, se for o caso. Oficie-se o Instituto de Identificação Civil e comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição.

Oportunamente, expeça-se certidão ao(à) advogado(a) nomeado(a), nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

José Bonifacio, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA